

1501420-68.2021.8.26.0603

Classe: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: ADRIANO PINTO DE OLIVEIRA

Comarca: Birigui

Foro: Foro de Birigui

Vara: 1ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 04/11/2022

... por si só, não afasta a tipificação do crime de tráfico. Aliás, atualmente, os traficantes vêm utilizando desse modo de agir (distribuição de pequenas porções entre vários entregadores), a fim de dificultar a apreensão da droga e a caracterização do crime de tráfico.

A confirmar a traficância, está a informação do próprio réu LUAN de que, na época do fato, trabalhava ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Birigui

Foro de Birigui

1ª Vara Criminal

Rua Faustino Segura nº 214, Birigui-SP - cep 16200-370

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às 17h00min

1501420-68.2021.8.26.0603 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1501420-68.2021.8.26.0603

Classe - Assunto:

Procedimento Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante - 2277911/2021 - DEL.POL.PLANTÃO BIRIGUI, 20771674 -

DEL.POL.PLANTÃO BIRIGUI, 2277911 - DEL.POL.COROADOS

Autor:

Justiça Pública

Réu:

LUAN FERNANDES DE CAMPOS e outro

Réu Preso

Tramitação prioritária

Juiz(a) de Direito: Dr(a). ADRIANO PINTO DE OLIVEIRA

S E N T E N Ç A

Processo n.º 1501420-68.2021.8.26.0603 (Controle nº 2057/2021).

VISTOS.

LUAN FERNANDES DE CAMPOS, menor de 21 anos, qualificado nos autos, foi preso em flagrante, denunciado e viu-se processado como incurso no artigo 33, caput, da Lei nº 11.343/2006, bem como artigo 309, da Lei nº 9.503/97, na forma do artigo 69,

caput, do Código Penal e MATEUS DA SILVA CAMPOS, menor de 21 anos, qualificado nos autos, foi denunciado e viu-se processado como incurso no artigo 33, caput, da Lei nº 11.343/2006, porque, no dia 11 de outubro de 2021, por volta das 20h30min, na Rodovia Vicinal José Fernandes Barbieri, cidade de Coroados, comarca de Birigui, agindo em concurso, traziam consigo 25 (vinte e cinco) eppendorfs de cocaína, pesando um total de 24,49 gramas, substância entorpecente que determina dependência física e psíquica, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar, conforme laudo de pericial de fls. 261/263.

Consta, ainda, que, nas mesmas circunstâncias de tempo e espaço acima descritas, LUAN FERNANDES DE CAMPOS, dirigiu veículo automotor, em via pública, sem a devida Permissão para Dirigir ou Habilitação, gerando perigo de dano.

A denúncia foi recebida em 08 de novembro de 2021, os acusados foram devidamente citados (fls. 117 e 126) e apresentaram defesas escritas às fls. 113 e 154/166.

Durante a instrução, foram colhidos os depoimentos de 02 (duas) testemunhas arroladas pela acusação, 03 (três) testemunhas arroladas pela defesa do réu LUAN, e 02 (duas) testemunhas arroladas pelo réu MATEUS, sobrevivendo, ao final, os interrogatórios dos réus (fls. 235/236).

Em alegações finais, o Ministério Público pleiteou a condenação dos acusados, nos exatos termos da denúncia (fls. 270/275).

Por outro lado, a defesa do réu MATEUS requereu a absolvição por insuficiência de provas. Subsidiariamente, requereu a aplicação da pena no mínimo legal; o reconhecimento da atenuante da menoridade penal relativa; a aplicação do redutor máximo previsto no §4º do artigo 33 da lei de drogas (fls. 278/279).

A defesa do corréu LUAN requereu a absolvição por falta de provas e, subsidiariamente, pediu a desclassificação para o delito elencado no § 3º do artigo 33 da Lei n.º 11.343/06; a aplicação da pena-base no mínimo legal; o reconhecimento da atenuante da menoridade penal relativa; a aplicação do § 4º, do artigo 33, da Lei n.º 11.343/06 (fls. 280/285).

É o relatório.

Decido.

Trata-se de ação penal pública incondicionada que se destina a apurar a responsabilidade dos acusados pela prática de condutas que, em tese, estariam a configurar o delito de tráfico ilícito de drogas (artigo 33, da Lei nº. 11.343/06 – ambos os réus) e conduzir veículo automotor sem habilitação (artigo 309, caput, do CTB – réu LUAN).

A ação penal é totalmente procedente.

Ao término da instrução criminal, e após um atento exame das provas existentes nos autos, não há como se deixar de reconhecer que a materialidade e a autoria dos fatos narrados na denúncia ficaram satisfatoriamente comprovadas.

Nesse sentido, temos: o auto de prisão em flagrante de fl. 01; a nota de culpa de fls. 06; o boletim de ocorrência de fls. 17/22; o auto de exibição e apreensão encartado às fls. 25/26; o laudo pericial de fls. 261/263; o relatório de fls. 90/93; o depósito de fl. 89; os depoimentos das testemunhas; e as indigestas e contraditórias negativas apresentadas pelos acusados em ambas as fases da persecução penal.

Na delegacia, o acusado MATEUS negou a prática do tráfico, afirmando que estava na casa de seu amigo Vinícius juntamente Thiago e Pixiteli, quando LUAN chegou e convidou todos para um churrasco em Braúna-SP. Foi o único que aceitou o convite. Estavam a caminho de Braúna-SP, quando a Polícia Militar cruzou, retornou e deu sinal sonoro e luminoso para parar a moto. Neste instante, LUAN pediu para jogar dois pacotes de drogas, que estavam com ele. Foram abordados e os policiais retornaram no local em que tinha jogado a droga e encontraram só um pacote com 25 pinos de drogas. Afirmou que sabia que LUAN estava com droga, pois iriam "curtir" no churrasco (fl. 04).

Na fase extrajudicial, o corréu LUAN disse que foi até a casa de Vinícius e convidou MATEUS para um churrasco em Braúna-SP. Entretanto, no caminho, passou em sentido contrário uma viatura da Polícia Militar, que fez o retorno, deu sinal luminoso e sonoro para parar a motocicleta. Neste instante, passou dois pacotes que estavam no meu bolso, sendo um com 25 (vinte e cinco) eppendorfs e o outro com 20

(vinte) eppendorfs, todos de cocaína, para MATEUS, que estava na garupa da moto, dispensá-los na rodovia. Disse que as drogas seriam consumidas por ele e MATEUS, e também venderia para GABRIEL, vulgo "Zoi Verde", por R\$ 10,00 (dez reais) cada eppendorf de cocaína. Disse que não tinha permissão ou habilitação para dirigir veículo automotor (fls. 05).

Já em juízo, o acusado MATEUS alterou parcialmente sua versão, afirmando que não sabia que LUAN estava com as drogas, só ficou sabendo disso no momento que LUAN lhe passou para dispensá-las na rodovia. LUAN estava conduzindo a motocicleta e não possuía habilitação para conduzir veículo automotor. Disse que dispensou apenas um pacote. Em nenhum momento estava auxiliando LUAN entregar as drogas para um comprador de Braúna-SP (fls. 235/236).

Já o acusado LUAN, em juízo, relatou que a droga lhe pertencia. Disse que consumiria a droga em Braúna-SP. Negou que estaria levando para vender. Durante o percurso, a droga estava com MATEUS e só havia um pacote de drogas com 25 porções. Não possuía CNH e estava conduzindo a motocicleta. Estava indo na casa de seu conhecido de nome Daniel. Disse que Gabriel, vulgo "Zóio Verde", também estava em Braúna, o qual não tem envolvimento com o tráfico. Afirmou que deu outra versão na delegacia porque estava com medo. Disse que consumia todo dia cocaína, sendo duas porções por dia, pela qual pagava R\$ 10,00 cada uma. Ganhava R\$ 1.200,00 de salário mensal, com o qual ajudava nas despesas da casa como contas de água e internet, pagava R\$ 260,00 mensais da prestação da motocicleta e mais R\$ 200,00 mensais da CNH que estava em processo para obtê-la (fls. 235/236).

Como se vê, o acusado MATEUS, na fase policial, disse que sabia que LUAN estava com as drogas; que eram dois pacotes e que LUAN lhe passou quando avistou os policiais para dispensar; no entanto, em juízo, MATEUS alterou sua versão e passou a dizer que não sabia que LUAN estava com os entorpecentes e que dispensou apenas um pacote. Por sua vez, na fase policial, o acusado LUAN disse que avistou os policiais e passou dois pacotes contendo porções de cocaína para MATEUS, dispensá-los na rodovia; que as drogas seriam consumidas por ele e MATEUS, e também venderia para GABRIEL, vulgo "Zoi Verde", por R\$ 10,00 (dez reais) cada eppendorf de cocaína; porém, em juízo, passou a dizer que não venderia as drogas para Gabriel, vulgo Zóio Verde"; que, durante o percurso, a droga estava com MATEUS; que só havia um pacote de drogas com 25 porções.

Diante das inúmeras contradições apontadas, relacionadas a pontos de fundamental relevância para o deslinde da causa, não há como se dar credibilidade às versões apresentadas pelos acusados, que restaram isoladas, se cotejadas às demais provas coligidas sob o crivo do contraditório, que apresentaram grau de idoneidade bem mais elevado, como se verá doravante, não passando de mero expediente utilizado na tentativa de se furtarem da responsabilização penal por condutas efetivamente praticadas.

Em relação ao delito de conduzir veículo automotor sem habilitação, praticado por LUAN, a confissão livre e espontânea prestada no processo serve como importante elemento de convicção para evidenciar a autoria e amparar a condenação, quando encontrar sustentação nos demais elementos de convicção produzidos. De outra parte, isolada a alegação do réu LUAN no sentido de que assumiu a prática do tráfico na fase policial porque estava nervoso na delegacia, tratando-se de alegação desprovida de fundamento e que foi afastada pelos demais elementos de prova colhidos na instrução.

Com efeito, as testemunhas Edmarcos Lorenceti Brito e Leandro Augusto Martins dos Santos, policiais militares, ouvidos em ambas as fases da persecução penal, relataram que avistaram dois indivíduos em uma motocicleta, que, ao virem a viatura, começaram a acelerar. O indivíduo que estava na garupa, MATEUS DA SILVA CAMPOS, não parava de olhar para trás e lançou dois objetos no mato ao lado da rodovia. Logo em seguida, foram abordados e revistados MATEUS e LUAN, não sendo achado nada de ilícito. Entretanto, retornando ao local em que os objetos tinham sido lançados, foram encontrados 25 pinos de cocaína. LUAN estava dirigindo veículo automotor, em via pública, sem a devida permissão para dirigir ou habilitação. Indagados, ambos acusados confessaram que estavam levando as drogas para um comprador em Braúna-SP, inclusive disse que eram 45 eppendorfs com drogas. (fls.

02, 03 e 235/236).

Os relatos dos policiais evidenciam que os réus incidiram na prática de tráfico ilícito de entorpecentes. e que LUAN conduzia veículo automotor sem habilitação. Anoto que o valor do depoimento de policiais militares, especialmente quando prestados em juízo, sob a garantia do contraditório, reveste-se de inquestionável eficácia probatória, não se podendo desqualificá-lo pelo só fato de emanar de agentes estatais incumbidos, por dever de ofício, da repressão penal.

Tal depoimento somente não terá valor quando se evidenciar o interesse do servidor na investigação penal, e quando seus depoimentos não encontrarem suporte em outros elementos probatórios idôneos.

Importante salientar que não existe qualquer circunstância que justificasse o interesse dos policiais em prejudicar o acusado, ou em imputar falsamente a ele a prática de condutas definidas como crimes, sobretudo porque ele não apontou nada que justificasse essa circunstância.

As testemunhas Valdecir Mesquita de Souza, Helton Marques Campos, Elaine Aparecida Fernandes de Campos, Elisangela Cristina Silva Campos e Marcio José da Silva, ouvidas em juízo, nada souberam dizer sobre os fatos, apenas tecendo comentários sobre os acusados.

No mais, a defesa do acusado LUAN não arrolou como testemunha a pessoa de nome Daniel, na casa de quem disse que fariam o churrasco em Braúna-SP e lá, supostamente, usariam as drogas apreendidas, nem arrolou a pessoa de nome Gabriel, alcunha "Zóio Verde", que também estaria na casa em Braúna-SP, providências essas que seriam de fácil consecução, caso fosse verdadeira a narrativa apresentada. Aliás, este último, segundo o que o réu Luan disse na delegacia, seria o comprador da droga para quem ambos os réus estariam levando para a cidade de Braúna.

De outra parte, os entorpecentes apreendidos, ou seja, 24,49 gramas de cocaína; as circunstâncias da abordagem dos réus (tentaram dispensar as drogas ao avistar os policiais militares), a forma de acondicionamento das drogas (distribuídas em porções prontas para comércio); a apreensão de dinheiro (R\$ 70,00) e celular; e a confissão informal dos acusados aos policiais militares, estão a caracterizar a traficância.

No que se refere aos entorpecentes, a perícia apontou que consiste realmente em "cocaína" (exame químico-toxicológico de fls. 261/263).

Nunca é demais lembrar que é desnecessária a prova de ato de comércio, bastando que o agente traga a droga consigo para essa destinação, ainda que futura, na medida em que a consumação não exige qualquer resultado.

Anote-se que o simples de fato de a droga não ter sido apreendida em grande quantidade, por si só, não afasta a tipificação do crime de tráfico. Aliás, atualmente, os traficantes vêm utilizando desse modo de agir (distribuição de pequenas porções entre vários entregadores), a fim de dificultar a apreensão da droga e a caracterização do crime de tráfico.

A confirmar a traficância, está a informação do próprio réu LUAN de que, na época do fato, trabalhava auferindo mensalmente a quantia de R\$ 1.200,00. Ora, somente com essa renda, como é cediço, não é crível que consiga o réu adquirir, para uso próprio, a quantidade de droga para o uso diário (duas porções de cocaína por dia, a R\$ 10,00 cada uma), o que só vem confirmar o tráfico, lembrando que o acusado afirmou que auxiliava nas contas da casa, pagava R\$ 260,00 de prestação mensal da motocicleta, R\$ 200,00 mensais da CNH que estava obtendo, e segundo ele, estava com pelo menos 25 porções de cocaína para consumir naquela noite.

Quanto ao dinheiro apreendido, o acusado LUAN não fez qualquer prova sobre a sua procedência lícita e, diante da prova acima analisada, não há como se deixar de reconhecer que é produto do tráfico de entorpecentes.

Assim, além da robusta prova acima analisada, há indícios mais que suficientes para a prolação de decreto condenatório. Aliás, neste ponto, tratando-se de delito, na maioria das vezes, praticado às escondidas, não se pode abrir mão dos indícios para o estabelecimento da verdade real. E a definição de indício vem estabelecida no próprio Código de Processo Penal, no artigo 239. Com isso, constata-se que o juiz formará a sua convicção na livre apreciação da prova, e, diante do nosso sistema processual, o indício é o fato provado que, por sua ligação íntima com o fato

probando, autoriza a concluir algo sobre este, até porque os indícios estão inscritos no título da prova, e, assim, a autoria do delito, pelo sistema do livre convencimento, pode ser demonstrada, validamente, pela força probante dos indícios. Sendo assim, não resta dúvida de que, no dia, horário e local indicados na denúncia, ambos os acusados traziam consigo 24,49 gramas de cocaína, substâncias determinantes de dependência física e psíquica, sendo que o faziam sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar, para entrega a consumo de terceiros; e o réu LUAN dirigiu veículo automotor, em via pública, sem a devida permissão para dirigir ou habilitação, gerando perigo de dano.

As condutas dos réus encontram tipicidade na exata correspondência com os delitos definidos nos artigos 33, caput da Lei nº. 11.343/06 (MATEUS e LUAN) e artigo 309, caput, do CTB (réu LUAN).

Inexistem causas que afastem a ilicitude das condutas, excluam a culpabilidade dos denunciados ou extingam a punibilidade. Neste ponto, o fato de os réus serem usuários de drogas, isso, por si só, ainda que verdadeiro, não os impediria de exercer a traficância. Muito pelo contrário, há grande afinidade entre uma e outra conduta. Se fossem viciados há um bom tempo, isso facilitaria o ingresso no submundo do crime, principalmente no mercado de substâncias tóxicas.

Em outros termos, mesmo que se admitisse a condição de serem os réus usuários de drogas, isso não excluiria a possibilidade de serem condenados como traficantes, porque são situações que não se excluem.

Quanto ao pedido da defesa do réu LUAN de desclassificação para o § 3º do artigo 33 da Lei de Drogas, a pretensão não comporta acolhimento.

Pelas provas produzidas nos autos, restou comprovada a prática do tráfico de drogas por parte dos acusados, que inclusive, confessaram informalmente aos policiais militares.

Portanto, não há que se falar em eventual oferecimento de drogas gratuito para tipificação do artigo 33, § 3º, da Lei de Drogas, lembrando que os réus sequer arrolaram como testemunhas as pessoas que estariam no churrasco para confirmarem suas versões.

Reconheço, pois, a ocorrência dos delitos e passo a aplicar as penas.

Tráfico de drogas (réus MATEUS e LUAN)

Os acusados são primários e não ostentam maus antecedentes, razão pela qual as circunstâncias do art. 59 do Código Penal lhes são favoráveis, o que autoriza a fixação da pena-base em seu mínimo legal, ou seja, 05 (cinco) anos de reclusão, e pagamento de 500 (quinhentos) dias-multa, em seu valor mínimo unitário, para cada um dos réus.

Na segunda fase, reconheço a atenuante da menoridade penal relativa (réu menor de 21 anos) para ambos os réus, no entanto, deixo de reduzir as penas, porque já fixadas em seus mínimos legais (Súmula 231 do STJ). No mais, não há agravantes ou outras atenuantes a serem consideradas.

Na terceira fase, não existem causas de aumento de pena a serem aplicadas, no entanto, preenchidos os requisitos do artigo 33, § 4º, da Lei nº. 11.343/06, reduzo as penas em 2/3 (dois terços), resultando em 01 (um ano) e 08 (oito) meses de reclusão, e pagamento de 166 (cento e sessenta e seis) dias-multa, no menor valor (art. 43, caput, da Lei nº 11.343/06), para ambos os acusados, a qual torno definitiva.

A redução está sendo aplicada no máximo em razão da quantidade da droga.

Conduzir veículo automotor sem habilitação (réu LUAN)

O acusado não ostenta maus antecedentes, razão pela qual as circunstâncias indicadas no art. 59 do Código Penal lhe são favoráveis, o que enseja a aplicação da pena no mínimo legal, ou seja, 06 (seis) meses de detenção.

Na segunda fase, reconheço as circunstâncias atenuantes da confissão espontânea e da menoridade penal relativa, no entanto, deixo de reduzir a pena, porque já fixada em seu mínimo legal (Súmula 231 do STJ). No mais, não agravantes ou outras

atenuantes a serem consideradas.

Na terceira fase, não há causas de diminuição ou de aumento de pena a serem consideradas.

Torno definitiva a pena em 06 (seis) meses de detenção.

Para este crime, praticado por LUAN, o regime inicial de cumprimento da pena privativa de liberdade será o aberto, nos termos do art. 33, § 2º, alínea "c", do Código Penal.

Observo que, diante dos diferenciados tipos de pena privativa de liberdade (reclusão e detenção), não poderá ser aplicado o concurso material para o réu LUAN, com a soma das penas. Fixo, assim, cada pena separadamente, observando-se, na fase de execução, o disposto no artigo 69, caput, 2ª parte, do Código Penal.

Quanto ao crime de tráfico de drogas, para ambos os réus, diante da gravidade das condutas, mesmo levando-se em conta a detração penal disposta na Lei nº 12.736/12 (art. 2º, que acrescentou o § 2º ao art. 387 do CPP), as penas aplicadas aos réus devem ser cumpridas no regime inicial fechado, obrigatoriamente, pois se trata de crime equiparado a hediondo, conforme estatuído no art. 2º, §1º, da Lei nº 8.072/90.

Neste ponto, anoto que a imposição coletiva vinculante quanto à vedação de fixação do regime inicial fechado para cumprimento da pena imposta aos condenados pelo crime de tráfico na modalidade privilegiada, determinada pelo voto monocrático do E. Relator Ministro Rogério Schietti Cruz (6ª Turma do C. STJ) em sede de HC nº 596.603/SP, foi cassada pela r. decisão exarada pelo Exmo. Ministro do C. STF, Alexandre de Moraes, no julgamento do RE nº 1.344.374, em 01/12/2021, conferindo ao julgador a liberdade de avaliar o regime prisional cabível em cada caso.

Ademais, em relação ao réu LUAN, infere-se inviável, de igual sorte, a alteração do regime prisional, na hipótese, com esteio no lapso que perdurou a prisão cautelar, porque não se tem notícia a respeito da real situação carcerária do acusado, isto é, se não registra outras condenações ou prisões processuais, nem quanto ao seu comportamento e conduta no cárcere, a revelar não existirem elementos seguros para a correta análise, nesta seara e de pronto, quanto a eventual direito à detração penal, emergindo mais adequado que o juízo da execução se manifeste por primeiro, à míngua de informações concretas.

Fixo cada dia-multa no valor mínimo unitário legal, ante a ausência de informações seguras sobre a capacidade econômica dos réus.

O acusado LUAN deverá continuar a responderem preso por este processo, pois assim permaneceram durante a instrução e ainda estão presentes os requisitos da custódia cautelar, como se verá doravante.

Já o acusado MATEUS não teve a prisão preventiva decretada e permaneceu solto durante a instrução, razão pela qual poderá continuar a responder ao processo em liberdade.

Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE a ação penal para

01) CONDENAR LUAN FERNANDES DE CAMPOS, qualificado nos autos, ao cumprimento da pena de 06 (seis) meses de detenção, em regime aberto, dando-o como incurso nas penas do artigo 309 da Lei nº. 9.503/97.

Apesar de preenchidos os requisitos do artigo 44, incisos I e II, do Código Penal (pena não superior a quatro anos e réu não reincidente em crimes dolosos), entendo não cabível a substituição, vez que admitir um traficante, prestar serviços em escolas e outras entidades públicas, colocaria em risco as pessoas que delas se utilizam, inclusive crianças inocentes, o que, de forma alguma, se pode admitir.

02) CONDENAR MATEUS DA SILVA CAMPOS e LUAN FERNANDES DE CAMPOS, qualificados nos autos, ao cumprimento, cada um, das penas de 01 (um) ano e 08 (oito) meses de reclusão, em regime inicial fechado (art. 2º, §1º, da Lei nº 8.072/90, com a redação da Lei nº 11.464/07), e pagamento de 166 (cento e sessenta e seis) dias-multa, no menor valor (art. 43, caput, da Lei nº 11.343/06), por infração ao artigo 33 da Lei nº. 11.343/06.

Consigno que o acusado LUAN ficou preso cautelarmente desde 11/10/2021 até a presente data, período sobre o qual fica reconhecida a detração penal, para fins de cumprimento do restante da pena, nos termos do que dispõe o artigo 1º da Lei nº 12.736/12.

Deve, no entanto, a Serventia, ao expedir a Carta de Guia, atentar para se consignar a condenação total constante do dispositivo acima, com as observações consignadas no parágrafo anterior (detracção penal).

Quanto ao tráfico de drogas, para ambos os réus, deixo de substituir as penas privativas de liberdade por restritivas de direitos, por entender incabível tal providência.

Não obstante o julgamento do Habeas Corpus n. 97.256, pelo Supremo Tribunal Federal, no qual se entendeu por inconstitucional a vedação à substituição por penas restritivas de direitos para o crime de tráfico, por afronta ao princípio da individualização da pena, até então não se trata de decisão proferida com efeito erga omnes.

Recentemente, foi editada a Resolução nº 5/2012, do Senado Federal, que, nos termos do artigo 52, inciso X, da Constituição Federal, suspendeu a execução de parte do § 4º do art. 33 da Lei de Drogas, que vedava de forma abstrata (sem análise do caso concreto) a conversão em penas restritivas de direito, declarada inconstitucional por decisão definitiva do Supremo em decisão no Habeas Corpus já mencionado acima. Com a mencionada Resolução, não se pode mais afirmar que o efeito do julgamento daquele habeas corpus não é para todos. Entretanto, a intenção do Supremo Tribunal Federal, ao decidir desta forma, e o Senado Federal, ao editar a resolução, foi somente deixar à prudente análise do magistrado do caso concreto se o réu tem ou não direito a ter a pena privativa de liberdade substituída por restritiva de direitos, e não que essa substituição seja admitida em qualquer caso de tráfico de drogas, indistintamente. Pensar assim seria um contrassenso.

Confira, neste sentido, decisão proferida em Apelação Criminal que analisou sentença proferida por este juízo:

"... Inviável, nesse passo, a pretendida substituição carcerária por restritivas de direito, porque, embora o teor da recente Resolução nº. 5/2012 do Senado Federal, fundada na decisão do Supremo Tribunal Federal proferida nos autos do Habeas Corpus, nº. 97.256/RS - mencionado nas razões recursais -, em controle difuso de constitucionalidade, in casu, permanece impossível, data vênua, a substituição prevista no artigo 44 do Código Penal, ou mesmo a concessão de sursis, pois o crime de tráfico de entorpecentes revela a gravidade peculiar que desestabiliza a vida em sociedade e fere de morte a saúde pública, pois enquanto fomenta, simultânea e irremediavelmente - até as pedras estão cansadas de saber -, a violência, a destruição de lares e das famílias e a prática de n crimes, sobretudo para o fim de viabilizá-lo, tanto assim que, por força de norma constitucional, é assemelhado aos delitos hediondos, cuja pena deve ser cumprida no regime prisional inicial fechado, determinação esta que se mostra incompatível com a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos ou com a suspensão condicional da pena, de modo que não se consegue compreender ou avaliar, por mais que se esforce, qual seria a pena substitutiva ou as condições do sursis adequadas ao traficante, emergindo sintomático que - até o momento - jurista sério algum tenha ousado sugerir-las..." (TJ-SP, Apelação Criminal nº 0009435-15.2010.8.26.0077, 5ª Câmara Criminal, rel. Des. Juvenal Duarte, j. 19.04.2012).

Ainda no mesmo sentido, confira julgamento proferido em processo que tramitou por essa comarca de Birigui:

"Também não faz jus a apelante à substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos.

A concessão da substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos aos condenados a tráfico de drogas é incompatível com a gravidade e as circunstâncias em que o crime é cometido, não havendo qualquer tipo de violação ao princípio da individualização da pena.

Este entendimento deve prevalecer, notadamente ao se considerar a vedação expressa trazida pelo artigo 44 da Lei de Drogas.

Com efeito, o benefício consistente na substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos tem por objetivo primordial o de possibilitar a

ressocialização de indivíduos de baixa periculosidade, que praticaram delitos de pequeno grau de lesividade social.

Traficantes de substâncias entorpecentes, sejam de pequeno, médio ou grande porte, não tem o perfil de iniciar o cumprimento de sua pena que não mediante encarceramento. Mesmo o pequeno traficante merece uma punição severa. Basta que a venda de drogas seja realizada uma única vez, para que cause uma série de malefícios ao consumidor, as quais virão a repercutir a toda a coletividade. Ressalta-se que uma das exigências previstas no artigo 44, inciso III, do Código Penal, para a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos é a de que os motivos e as circunstâncias indiquem como suficiente tal medida, para a repressão do agente da conduta delituosa.

Conforme já fundamentado, tal benefício não se coaduna com as graves consequências que a mercancia de substâncias entorpecentes causa, não só ao usuário, com uma rápida deterioração da sua saúde física e mental, mas também ao corpo social (desestrutura familiar, estímulo à prática de outros crimes, como homicídios, latrocínios, extorsões etc.).

Muito embora o Plenário do Supremo Tribunal Federal, no julgamento do "Habeas Corpus" nº 97256/RS, tenha expressão "vedada a conversão em penas restritivas de direitos", contida no § 4º, do artigo 33, da Lei 11343/06, é de se ressaltar que tal decisão não possui o erga omnis.

E mesmo a resolução nº 5 do Senado Federal, de 15 de fevereiro de 2012, que suspendeu a eficácia da referida expressão, não acarreta direito subjetivo do agente que praticou o grave delito do tráfico de entorpecentes a tal conversão da pena privativa de liberdade em restritiva de direitos.

Frise-se, ainda, que o artigo 44 da Lei de Drogas mantém tal vedação ao crime de tráfico de drogas, previsto no artigo 33, caput. Considerando que o § 4º é tão somente uma causa de diminuição do delito previsto no caput - e não um crime autônomo -, é possível concluir que a vedação a ele também se aplica.

Neste aspecto, ensina Guilherme de Souza Nucci que "(...) o fato de haver sido prevista uma causa de diminuição de pena para o traficante primário, de bons antecedentes, sem outras ligações criminosas, não afasta a tipificação da sua conduta como incursas no artigo 33, caput e § 1º, que são consideradas similares a infrações penais hediondas, como se pode observar pelas proibições enumeradas no artigo 44 da Lei 11343/06. Salienta-se, ademais, o cuidado legislativo em vedar a aplicação da substituição da pena privativa de liberdade por pena restritiva de direitos, típica opção de política criminal para o tráfico ilícito de drogas. Não se pode criar uma nova infração penal, a partir da mera aplicação de causa de diminuição de pena. Por isso, o tráfico ilícito de drogas será sempre considerado equiparado a hediondo, ainda que comporte, por opção legislativa, pena mais branda, quando os requisitos do § 4º estiverem presentes" (in "Leis Penais e Processuais Penais Comentadas", 5ª ed., São Paulo, Revista dos Tribunais, 2010, p.372).

Desta forma, NEGOU PROVIMENTO ao recurso, mantendo, integralmente, a respeitável sentença de primeiro grau" (Apelação Criminal nº 0002364-20.2014.8.26.0077. Rel. Toloza Neto).

O réu LUAN deverá continuar a responder preso por este processo, pois foi preso em flagrante delito e sua prisão foi convertida em preventiva (fls. 55/58), ocasião em que foram expostos os fundamentos necessários para a custódia cautelar, os quais reitero, aqui, como razão de decidir, assim como aqueles expostos a fls. 176/177, que indeferiu o pedido de liberdade provisória.

Por fim, anoto que o Habeas Corpus impetrado em favor do acusado LUAN teve a liminar indeferida e, ao final, a ordem denegada (fls. 134/136 e 288/297), demonstrando o acerto deste Juízo na manutenção da prisão cautelar dos acusados. Recomende-se o acusado LUAN FERNANDES DE CAMPOS na prisão em que se encontram.

Por fim, em atenção ao disposto no artigo 316, parágrafo único, do Código de Processo Penal, após 85 (oitenta e cinco) dias contados da publicação da sentença, tornem os autos conclusos para revisão da necessidade de manutenção ou não da decisão que manteve a prisão preventiva, mantendo-se os autos na fila "acompanhamento de prisão preventiva".

A incineração do entorpecente apreendido já foi determinada e realizada a fls. 143 e 153, nada mais havendo a ser decidido a respeito.

Com fundamento nos artigos 91, inciso II, alínea "b", do Código Penal, e 63 da Lei nº. 11.343/06, decreto o perdimento, por serem produtos do tráfico de entorpecentes praticado pelos acusados, do dinheiro (R\$70,00 - depósito fls. 89) e motocicleta apreendidos às fls. 25/26.

Após o trânsito em julgado, comunique-se o "Senad" quanto ao perdimento supradeterminado, instruindo o ofício com cópias do auto de exibição e apreensão, da presente sentença e eventual Acórdão, bem como das certidões de trânsito em julgado para as partes.

Diante da natureza dos demais objetos apreendidos (celular), determino, desde já, sua destruição, que deverá ser cumprida somente após o trânsito em julgado, expedindo-se o necessário e comunicando-se a Sala de Armas e Objetos Apreendidos. Oficie-se também à Delegacia de Polícia de origem, informando sobre o perdimento e destruição, instruindo-se o ofício com cópias.

Fixo cada dia-multa no valor mínimo unitário legal, ante a ausência de informações seguras sobre a capacidade econômica dos réus.

Com o trânsito em julgado da presente, oficie-se ao Cartório Eleitoral, nos termos do artigo 28 da Resolução nº 23.399/13 do TSE, instruindo o ofício com cópias da presente sentença e eventual Acórdão, bem como das certidões de trânsito em julgado para as partes.

Custas na forma da Lei.

P. R. I.

Birigui, 04 de novembro de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA